

1513806-09.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO IMPEDE A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513806-09.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513806-09.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO MORAIS DO ESPIRITO SANTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

FERNANDO MORAIS DO ESPÍRITO SANTO foi denunciado e se vê processado pela prática do delito descrito no art. 155, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea "j)", ambos do Código Penal, porque, no dia 26 de abril de 2022, por volta das 13h50min., durante a vigência do estado de calamidade pública, decretada por ocasião da Pandemia do COVID-19, na Rua Helvetia, nº 983, Santa Cecília, nesta cidade e capital, subtraiu, para si, um aparelho de telefonia da marca Motorola, avaliado em R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), pertencente à vítima Flávia Mara da Silva Araújo.

Recebida a denúncia, o acionado foi citado pessoalmente, sendo apresentada resposta escrita à acusação.

Decisão saneadora proferida na sequência.

Em audiência foi colhida a prova oral e interrogado o acusado.

Nos debates, as partes fizeram suas ponderações finais.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido procede.

Materialidade decorre do Auto de Prisão em Flagrante, de fls. 01/02, do Boletim de Ocorrência de fls. 03/05, bem como do Auto de Exibição, Apreensão e Entrega, a fls.

21/22. Autoria delitiva emerge da prova, das circunstâncias e das declarações firmes e harmônicas da vítima e dos guardas municipais.

Com efeito, o acusado foi preso em flagrante delito, na posse direta do bem de propriedade da vítima, o qual havia sido recém-subtraído, não fornecendo qualquer explicação minimamente convincente para tanto. Além disso, foi prontamente reconhecido pela proprietária do celular, como a pessoa que furtou o aparelho instantes atrás.

Interrogado na etapa policial, negou a prática delitiva (fls. 09), em enredo reiterado nesta audiência.

Contudo, apresentou enredo fantasioso e inventivo, de todo embusteiro e inverossímil, revelador, unicamente, do espírito aguerrido e aventureiro do criminoso, de simplesmente pretender negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir.

Triste investida!

Doutro lado, a prova, de todo séria.

Chamada a prestar declarações em Juízo, a vítima Flávia Mara Da Silva Araújo declarou que, no dia dos fatos, havia acabado de sair do trabalho e, quando caminhava, acabou encontrado um amigo, zelador de um prédio, parando para conversar rapidamente. Enquanto conversavam, pegou o seu celular que estava na sua bolsa e no mesmo momento o acionado (reconhecido em audiência) passou correndo e puxou o aparelho, correndo em direção à antiga "cracolândia", na Praça Princesa Isabel. Imediatamente a declarante começou a gritar "pega ladrão", sendo que a população correu atrás do acionado, juntamente com policiais que passavam pelo local, certo que o acionado dispensou o celular da declarante pouco antes de ser preso. Ato contínuo, a declarante se aproximou dos policiais e narrou o ocorrido, reconhecendo imediatamente o acionado e o seu celular, recuperado pelos policiais.

Amparando as palavras da vítima, temos, então, as declarações firmes dos policiais militares, responsáveis pela prisão do acusado.

Ouvidos em audiência judicial, Fernando De Deus Oliveira e Paulo De Camargo Mesquita declararam, em versões absolutamente consentâneas, que, estavam em patrulhamento pela área dos fatos, quando viram o acionado correndo a pé e ouviram populares gritando "pega ladrão" (sic), de modo que se aproximaram para abordá-lo, logrando a abordagem com a ajuda da população. Quando estava prestes a ser alcançado, o acionado dispensou um aparelho celular no meio da rua, o qual foi recuperado. Logo em seguida, uma mulher se aproximou dizendo que o acionado havia acabado de subtrair seu aparelho celular, o reconhecendo de imediato e confirmando que aquele celular, dispensado pelo suspeito durante a fuga, era o seu aparelho subtraído instantes atrás. Diante do exposto, deram voz de prisão em flagrante ao suspeito e conduziram as partes até a presença da autoridade policial.

Consigno que nada há nos autos a indicar que as testemunhas, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas ou gerasse suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

Da mesma forma em relação às palavras da vítima, que também não conhecia o réu anteriormente e motivo algum possuía para maldizê-lo.

Neste sentido, observo que há consonância e harmonia entre as declarações da vítima e dos policiais militares, confirmando a narrativa contida na Denúncia, no sentido de que o réu subtraiu o aparelho celular de propriedade da vítima.

Analisando a prova oral em seu conjunto, dúvida não me paira de que o acionado, visando cometer o crime de furto, visualizou a vítima na via pública, com seu aparelho celular em mãos, e, assim, correu em sua direção, apanhando-o de inopino e prosseguindo em fuga na posse do celular.

Não obstante, foi perseguido e finalmente detido pelos policiais militares ouvidos nesta oportunidade como testemunhas.

Quando de sua abordagem, em que pese a res não tenha sido encontrada em seu poder imediato, ambos os policiais declararam ter visto o ora acusado dispensar o aparelho durante a fuga, instantes antes de ser detido.

Bem assim, recuperado o telefone abandonado pelo réu, a vítima reconheceu o aparelho como seu, exatamente o que havia sido recém-furtado. Deste modo, a res furtiva foi visualizada em poder direto do acusado, muito embora sua vã tentativa de se livrar do produto do crime, circunstância absolutamente incriminadora e para a qual não conseguiu apresentar justificativa alguma. Como se sabe, o encontro da res em poder do furtador gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia e inverossímil transmuta a posição em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório. (Apelação nº 519.559/7, Julgado em 09/05/1.988, 11ª Câmara, Relator: - Segurado Braz, RJDTACRIM 1/103).

Confira-se, ainda: A apreensão de coisa furtada em mãos de alguém, acarreta-lhe o ônus de oferecer para o fato (comprometedor, em princípio) explicação razoável. Não o arrostando, milita contra o réu presunção de autoria de infração penal. (Apelação nº 569.933/2, Julgado em 01/03/1.990, 7ª Câmara, Relator: - Corrêa de Moraes, RJDTACRIM 6/132); Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificativa inequívoca. (Apelação nº 569.323/8, Julgado em 12/03/1.990, 10ª Câmara, Relator: - Sidnei Beneti, RJDTACRIM 6/134); Segundo o art. 156 do CPP, a apreensão da res furtiva em poder do agente enseja inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa demonstrar convincente versão acusatória de tal circunstância. (Apelação nº 596.861/6, Julgado em 14/02/1.990, 9ª Câmara, Relator: - Nogueira Filho, RJDTACRIM 6/140); Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída, em poder do agente, autoriza a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-se justificativa inequívoca, de modo que, a explicação dúbia e inverossímil transforma a presunção em certeza e autoriza o desfecho condenatório. (Apelação nº 792.381/8, Julgado em 31/05/1.993, 11ª Câmara, Relator: - Roberto Mortari, RJDTACRIM 18/47); Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmudara em certeza autorizando o desate condenatório. (Apelação nº 795.805/5, Julgado em 25/05/1.993, 4ª Câmara, Relator: - Passos de Freitas, RJDTACRIM 18/66); Em tema de delito patrimonial, a efetiva apreensão da "res furtiva" em poder do agente inverte o ônus da prova. (Apelação nº 863.933/4, Julgado em 28/06/1.994, 13ª Câmara, Relator: - Teixeira de Freitas, RJDTACRIM 22/126); A apreensão, ainda que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de certeza em relação a autoria. (Apelação nº 932.599/2, Julgado em 10/04/1.995, 11ª Câmara, Relator: - Fernandes de Oliveira, RJDTACRIM 27/167); A apreensão da res subtraída em poder do acusado gera a presunção de autoria, invertendo o ônus da prova. (Apelação nº 1.046.821/3, Julgado em 03/04/1.997, 2ª Câmara, Relator: - Osni de Souza, RJTACRIM 34/309).

Não bastasse, a vítima reconheceu o ora acusado como o autor do delito, tanto no local dos fatos, imediatamente após a sua detenção pelos policiais, quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Neste sentido, é certa a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de furto e na modalidade consumada, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp 1.524.450, que entendeu pela aplicação da Teoria da Apprehensio (ou Amotio) nos casos de furto, delimitando-se a tese nos seguintes termos: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

Responde, portanto, pela prática do crime de furto simples consumado, nos termos do art. 155, caput, do Código Penal.

Bem divisada a responsabilidade do acionado, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, contando o réu com uma longa lista de condenações pretéritas – inclusive pelo crime de homicídio –, conforme demonstra a certidão de fls. 128/135, das quais tomo nesta etapa as mais antigas, já atingidas pelo lapso depurador quinquenal, para fins de

reconhecimento de seus maus antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal, sem prejuízo das outras condenações mais recentes, a serem avaliadas na fase subsequente.

Anoto, neste sentido, que a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça e do C. Supremo Tribunal Federal já vinha reconhecendo a possibilidade da consideração de penas extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes, para fins de dosimetria da pena, conforme se verifica dos julgados abaixo colacionados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE.

1. Condenação criminal transitada em julgado há mais de 5 (cinco) anos, embora não possa ser utilizada para configurar a reincidência (art. 64, I, do Código Penal), pode ser considerada como maus antecedentes. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO IMPEDE A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES.

1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.

2. As condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes do Recorrente para fins de exacerbação da pena-base.

3. Recurso a que se nega provimento.

Tal orientação, todavia, foi sedimentada de modo definitivo pelo Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.818, com repercussão geral reconhecida, em que, por maioria de votos, fixou-se a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Destarte, o transcurso do lapso depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal desconstitui apenas a reincidência do acusado, não impedindo que eventuais condenações extintas há mais de cinco anos sejam reconhecidas como maus antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Frente a tal quadro, fixo a pena base do acusado em patamar 1/6 superior ao mínimo, estabelecendo o cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano e dois meses de reclusão, além do pagamento de pena pecuniária em valor correspondente a onze dias multa.

Em segunda fase, não há atenuantes a favorecer o acusado.

Doutro lado, de rigor o reconhecimento da condição de reincidente que ostenta, já tendo sido condenado recentemente por roubo, direção perigosa, ameaça e resistência, conforme fls. 128/135, condenações estas em relação às quais não decorreu o período depurador quinquenal – inclusive estando o acusado em livramento condicional quando da prática delitiva objeto destes autos.

Doutro lado, revendo posicionamento anterior, me convenço que na espécie não seja o caso de reconhecer a agravante descrita na denúncia (crime praticado durante período de calamidade pública), ausente, na prova, qualquer indicativo concreto de que o acionado se prevaleceu da pandemia para a prática do crime em questão, o que seria imprescindível a render espaço para reconhecimento da agravante.

Confira-se: Agravante prevista pelo art. 61, II, alínea j, do CP não prospera. A situação de calamidade em nada facilitou a ação criminosa, não havendo que se falar em enfraquecimento na proteção do bem jurídico diante do estado emergencial e de aproveitamento do acusado daquela situação. (Apelação Criminal nº 1511782-27.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 18 de março de 2022, rel. Desembargador

Marcos Alexandre Coelho Zilli)

Ou seja, ausente prova do nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta imputada ao acionado, incomprovado, então, que o acionado tenha se valido de alguma fragilidade ensejada pela pandemia para praticar o crime, seu reconhecimento se mostra impossível.

Sobre o tema, ainda: Habeas Corpus nº 625645-SP, rel. Ministros Félix Fischer; AgRg no Habeas Corpus nº 717.298-SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas; AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior.

Deste modo, considerando a agravante decorrente da multirreincidência do acusado, exaspero suas reprimendas em 1/4, culminando no cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano, cinco meses e quinze dias de reclusão e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a treze dias multa, fixados estes no patamar mínimo previsto em lei, reprimendas que torno definitivas, na medida em que não há causas de aumento ou diminuição de penas a ser valoradas.

O acusado cumprirá a pena corporal no regime inicial fechado.

Isso porque, em que pese o quantum da pena corporal a ele aplicada não seja extremamente elevado, certo é que se trata de réu multireincidente e com maus antecedentes, estes que expressamente valorados na etapa inicial da dosimetria.

Assim, tudo leva a crer que suas condenações passadas não surtiram o efeito esperado, de dissuadir o réu da senda criminoso, motivo pelo qual, neste momento, faz-se necessário maior rigor na repreensão de sua conduta.

Destarte, considerando o acima exposto, de rigor a fixação do regime inicial fechado para o desconto inicial da pena de reclusão.

Não há espaço para a substituição de sua reprimenda corporal por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal, em se tratando de acionado reincidente, ausente, ainda, requisito subjetivo indicativo de suficiência da medida.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado, como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine a análise, como forma de dirimir a controvérsia posta em julgamento.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu FERNANDO MORAIS DO ESPÍRITO SANTO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano, cinco meses e quinze dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a treze dias multa fixados no valor unitário mínimo previsto em lei, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

Sensíveis os requisitos que fundamentaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva do réu, e ainda mais agora, tendo sido condenado a duras penas, de modo que, acaso posto em liberdade, invariavelmente não se colocará de modo voluntário ao cumprimento de suas reprimendas, mantenho a prisão preventiva do sentenciado.

Assim se garante a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém nos limites do disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de junho de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei
Federal nº 11.419/06